

《【문제4.3-1】 특별수권사항에 대해 설명하시오. (25점)》

<문제4.3의 물음1> 특별수권사항의 의의, 구체적 범위, 특별수권없는 대리의 효력

I. 소송대리권 범위의 법정주의와 특별수권사항의 의의

1. 소송대리권 범위의 법정주의 [민사소송법 제90조 제1항]

- '소송법상 소송대리인의 권한 범위'를 '전적'으로 '사적 계약에만 의존'하게 하면 '소송 상대방'이 '예상치 못한 불이익'을 입기 쉽고, '소송절차'의 '확실적·안정적'인 '진행'을 '해치게' 된다. 따라서 우리 "민사소송법"은 '소송대리인의 권한 범위'를 '법률'로 '확일화'하여 '직접 규정'하는 '법정주의'를 '채택'하고 있다.

2. 특별수권사항의 의의

- '소송대리인'은 위임받은 소송에 대하여 소의 제기나 화해 등 일체의 소송행위를 할 수 있는 '일반적 대리권'을 가진다. 다만, '소송물의 처분'이나 '소송의 종료' 등 '본인의 실체적 권리관계'에 '심대한 영향'을 미치는 '특정 소송행위'에 대해서는 '본인'의 '명시적'이고 '개별적'인 '권한 수여'를 '요구'하는데, 이를 '특별수권사항'이라 한다.

II. 구체적 특별수권사항의 범위

1. 소송의 개시·종결 등에 관한 사항 [민소법 제90조 제2항 제1호·제2호]

- 본인의 '적극적인 의사 결정' 및 '처분의사'가 '필수'적인 항목들로서, '반소의 제기', '소의 취하', '화해', '청구의 포기·인낙', '독립당사자참가 소송탈퇴'를 하려면 특별수권을 별도로 받아야 한다.

2. 대리인 선임 및 상소 등에 관한 사항 [민소법 제90조 제2항 제3호·제4호]

- 소송대리인이 자신이 가진 대리권에 기초하여 다른 대리인을 선임하는 '복대리인의 선임', 심급을 이동시키거나 소송을 종료시키는 '상소의 제기 또는 취하', '대리인의 선임'을 하는 경우에도 반드시 특별수권이 존재하여야 한다.

III. 특별수권 없는 대리행위의 효력 및 본인의 추인 가부

1. 특별수권 없는 대리행위의 효력

(1) 원칙

- 특별수권이 결여된 채 이루어진 소송대리인의 소송행위는 '소송법상 무권대리행위'가 되어 '원칙적'으로 '무효'이다.

(2) 간과 판결 효과

- 다만, 이러한 하자를 법원이 '간과하고 본안판결'을 선고한 경우, '판결이 확정되기 전'에는 '상소(항소 및 상고)를 제기'하여 '판결을 취소'할 수 있고 '판결이 이미 확정'되었다면 '재심의 소를 제기'하여 구제받을 수 있다.

2. 본인의 추인 가부

(1) 추인의 소급효와 요건

- "민사소송법 제97조"가 "제60조"를 '준용'하여 무권대리인의 소송행위라도 '소송경제 및 당사자의 이익'을 위해 '본인'이 '사후에 추인하는 것'을 '허용'한다. '본인'의 '적법한 추인'이 있으면 '무권대리 소송행위'는 '행해진 시점'으로 '소급'하여 '대리권이 있었던 것과 동일'하게 '유효'해진다.

(2) 추인의 방식 및 시기적 한계

- 추인의 방식은 반드시 '서면'이나 '명시적 언동'으로만 해야 하는 것은 '아니'며, 무권대리 소송행위의 결과를 '묵묵히 받아들이는 등'의 '묵시적 방식'으로도 '가능'하다. 추인을 할 수 있는 '시기'는 소송절차의 안정을 지나치게 해치지 않는 한 '판결이 확정되기 전'까지이며, '사실심'은 물론 '상고심'에서도 '자유롭게 추인'할 수 있다.

IV. 결론

- '소송대리권 범위의 법정주의 체제 하'에서 '특별수권사항'은 '대리인'의 '독단적인 권리 처분 행위'로부터 소송당사자 '본인'의 '실질적 이익'을 두텁게 '보호'하기 위한 '법률상의 안전망'이다. 따라서 '법원'은 '소송절차의 정당성'과 '사법 신뢰'를 확보하기 위해 대리권의 존부 및 '특별수권 구비 여부'를 '직권'으로 '엄격'하게 '조사'하여야 한다. 다만, 절차적 흠결이 발생한 대리행위에 대해서는 사후 추인 제도를 유연하게 조화시킴으로써 불필요한 소송 지연을 막고 '사법자치'를 '조화롭게 실현'하여야 할 것이다.